

1502028-33.2019.8.26.0572

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: AUGUSTO RACHID REIS BITTENCOURT SILVA

Comarca: São Joaquim da Barra

Foro: Foro de São Joaquim da Barra

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 07/03/2022

... das drogas e agia em nítida ação de tráfico de drogas. Com efeito, os policiais relataram que receberam denúncia anônima, dando conta do tráfico de drogas no local. De posse das informações, deslocaram ao local e encontraram o acusado nas circunstâncias registradas na delação. Ressalto ainda que todos os dados informados na denúncia anônima foram constatados pelos policiais e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Joaquim da Barra

Foro de São Joaquim da Barra

1ª Vara

Travessa Cleiton Zanini, São Joaquim da Barra - SP - cep 14600-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1502028-33.2019.8.26.0572 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502028-33.2019.8.26.0572

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas

Autor:

Ministério Público

Réu:

LUCIANO DA SILVA LOPES

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). AUGUSTO RACHID REIS BITTENCOURT SILVA

Vistos.

I - RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu denúncia contra LUCIANO DA SILVA LOPES, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.434/06, acusando-o de no dia 13 de novembro de 2019, por volta das 20h30, na Rua Niterói, nº 1674, Residencial Espigão, nesta cidade e comarca de São Joaquim da Barra, vender 01 (uma) porção de "cocaína" a Dejair dos Santos, conforme laudo de constatação provisória, substância entorpecente que causa dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Consta ainda, que na posse do acusado foi apreendida a quantia de R\$ 2.480,00 (dois mil quatrocentos e oitenta reais) em espécie (f.01/02).

O acusado foi preso em flagrante. Realizada audiência de custódia, oportunidade em que a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva por esse Juízo. Na mesma oportunidade o Ministério Público ofereceu denúncia contra o acusado, acima resumida, sendo o acusado intimado para apresentar defesa (f.58/66).

O advogado do réu apresentou defesa prévia (f.84).

Decisão de f. 86/87 recebeu a denúncia, e designou audiência de instrução e julgamento.

Realizada audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa. Ao cabo da colheita de testemunhos, o réu foi interrogado. Na mesma oportunidade, o Ministério Público apresentou alegações finais pugnando pela condenação do réu nos exatos termos da denúncia (f.116/131).

Decisão de f.140/142 concedeu liberdade provisória ao acusado.

A Defesa, por seu turno, arguiu insuficiência de prova para a condenação. Pugnou subsidiariamente, pela desclassificação para a figura prevista no artigo 28 da lei 11.343/06, ou, ainda, o reconhecimento do tráfico privilegiado (f. 182/192).

É o relatório. Fundamento e decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Não há preliminares e incidentes pendentes de saneamento, pelo que passo a julgar a imputação formulada pelo Ministério Público.

O Ministério Público acusa LUCIANO DA SILVA LOPES dando-o como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

O artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, que cuida do denominado delito de “tráfico de drogas” possui a seguinte redação:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.”

De início, consigna-se que ação deve ser julgada procedente.

A cláusula do devido processo legal e o princípio da presunção de inocência exigem que o órgão oficial de acusação suporte o inteiro ônus da prova de culpabilidade do réu, além de uma dúvida razoável (beyond a reasonable doubt). A mera dúvida resolve o processo em favor do acusado. “A presunção de inocência, princípio cardeal no processo criminal, é tanto uma regra de prova como um escudo contra a punição prematura. Como regra de prova, a melhor formulação é o “standard” anglo-saxônico - a responsabilidade criminal há de ser provada acima de qualquer dúvida razoável -, consagrado no art. 66, item 3, do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional.”, consoante precedente do STF, na AP 521, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 05.02.2015.

A materialidade do delito de tráfico foi amplamente demonstrada e provada, tendo em vista o auto de prisão em flagrante delito (f. 03), o boletim de ocorrência (f. 10/12), o auto de exibição e apreensão (f.13/14), o laudo de constatação de f.16/18 e do exame toxicológico (f. 114/115) e por toda a prova oral colhido sob o crivo do contraditório. Consigne-se, por fim, que a materialidade é fato incontroverso.

O laudo definitivo de f. 114/115 evidenciou a presença do composto químico METIL BENZOIL ECGONINA (cocaína), no material analisado. Substância que se encontra relacionadas na Lista “F” da Portaria n. 344 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, como drogas entorpecentes e de uso proscrito no Brasil.

Quanto à autoria, o dolo e tipificação, vejo que há provas suficientes, acima de uma dúvida razoável, de que o acusado estivesse praticando o crime de tráfico de drogas.

Realizada audiência de instrução e julgamento as testemunhas e o réu foram ouvidos, vejamos:

A testemunha DEJAIR DOS SANTOS, ouvida em juízo, relatou que no dia dos fatos estava com Eliana. O acusado levou até eles uma porção de cocaína adquirida pelo valor de R\$ 20,00 (vinte reais). Os tramites da compra se deram via Whatsapp, utilizaram o termo "galinha" para se referirem à droga. Foi a primeira vez que adquiriu entorpecentes do acusado. Em outro momento Eliana adquiriu drogas com o réu, utilizando como moeda de troca relação sexual (mídia digital).

A testemunha ELIANA APARECIDA GARCIA DE SOUZA, ouvida em juízo, relatou que no dia dos fatos convidou DEJAIR para tomarem cervejas na casa dele. Nesta situação entraram em contato com LUCIANO para a aquisição de drogas. Assim, levou o dinheiro até o portão. Em meio a alguns flertes com o réu entraram na casa. Disse que "ficou" com acusado, e, na época trabalhava com "garota de programa". A porção de cocaína levada pelo acusado para DEJAIR custou R\$ 20,00 (vinte reais) (mídia digital).

A testemunha OSCAR GOMES DA SILVA, policial militar, ouvido em juízo relatou que participou da ocorrência. Abordaram o acusado quando ele estava saindo do local. Encontraram com ele cerca de R\$ 2.480,00 (dois mil quatrocentos e oitenta reais), espalhados em seus bolsos. Com a testemunha DEJAIR, foram encontrados dois eppendorfs em seu bolso e, em sua cueca três capsulas já usadas, de cor cinza. ELIANA, que também estava no local dos fatos, relatou que havia feito programa com o acusado, que foi pago com capsulas de cocaína, que repassou para DEJAIR. Foram apresentadas por DEJAIR mensagens trocadas com o acusado, encomendando cocaína, utilizando o termo "galinha" para se referirem à substancia, visto que o réu trabalhava como açougueiro. Em resposta ao pedido LUCIANO afirmou que não levaria cervejas por conta da chuva. ELIANA relatou que viu DEJAIR pagando a quantia de R\$ 20,00 (vinte reais) pela droga. O acusado é conhecido nos meios policiais (mídia digital).

A testemunha THIAGO ROBERTO TOGNATI SILVEIRA, policial militar, ouvido em juízo, relatou que participou da ocorrência. Após denúncia, dirigiram-se até o local, em revista pessoal localizaram com o acusado cerca de R\$ 2.480,00 (dois mil quatrocentos e oitenta reais). Deslocaram-se até a casa de DEJAIR, em revista pessoal encontram com ele, duas cápsulas de cocaína em seu bolso, além de três capsulas em sua cueca, parcialmente consumidas. Quando indagado sobre a origem dos entorpecentes, DEJAIR apontou que uma das capsulas havia adquirido de LUCIANO pelo valor de R\$20,00 (vinte reais), inclusive mostrou às autoridades mensagens em que encomendava os itens com o réu. Na mensagem de voz DEJAIR pede a LUCIANO uma "galinha", termo utilizado como sinônimo para cocaína, visto que o réu trabalhava como açougueiro, além de R\$ 10,00 (dez reais) em cervejas. Nas mensagens, LUCIANO disse que não iria levar as "cervejas" por estar chovendo, e que levaria apenas a "galinha". No interior da casa havia uma testemunha que alegou que ter feito programa com o acusado, que foi paga com cocaína, que deu para DEJAIR. Na residência do acusado nada de ilícito foi localizado (mídia digital)..

O acusado LUCIANO DA SILVA LOPES, interrogado em juízo, negou as acusações e, relatou que foi até a casa de DEJAIR para "ficar" com ELIANA. A mulher ameaçou o acusado dizendo que se ele não entregasse dinheiro a ela, chamaria a policia. O dinheiro encontrado com ele era proveniente de seu pagamento salarial, trabalha em um supermercado, o dinheiro encontrado seria utilizado para pagar a fatura de seu cartão de crédito (mídia digital).

Esse é o teor da prova oral.

Nessa quadra, joeirado o acervo probatório, tenho que ficou provado que o acusado era o proprietário das drogas e agia em nítida ação de tráfico de drogas. Com efeito, os policiais relataram que receberam denúncia anônima, dando conta do tráfico de drogas no local. De posse das informações, deslocaram ao local e encontraram o acusado nas circunstâncias registradas na delação. Ressalto ainda que todos os dados informados na denúncia anônima foram constatados pelos policiais e que seus depoimentos estão de acordo com as demais provas do processo.

Ademais, os policiais confirmaram que as denúncias indicavam a prática de tráfico de drogas pelo acusado, e no local dos fatos, presenciaram o acusado deixando a residência de DEJAIR, o qual confirmou ter pago R\$20,00 (vinte reais) ao acusado, pela porção de cocaína, bem como, que a testemunha ELIANA realizou programa com o acusado, que foi pago por meio de entorpecentes, fatos que também foram confirmados pela testemunha ELIANA, evidenciando a finalidade mercantil.

Ademais, as referidas testemunhas apresentaram aos policiais mensagens no celular referentes a tratativa das drogas, com o acusado, o que restou claro, pela prova oral colhida em juízo.

De mais a mais, sabe-se que a palavra dos policiais não pode ser desmerecida, pois eles estavam exercendo a função investigativa, inerente ao cargo em que foram investidos, devendo, pois, seus depoimentos serem aceitos, ainda mais porque coerentes com os elementos trazidos aos autos. De se observar que seus depoimentos só não teriam valor probante se restasse evidenciado um interesse particular na persecução criminal, ou então, se a versão dada não tivesse encontrado suporte nos demais elementos de prova, ou se tivessem agido facciosamente, o que não é o caso em apreço. Sobre a validade dos testemunhos insuspeitos dos policiais, vejamos a farta orientação jurisprudencial:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA. VALIDADE PROBATÓRIA DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS CONFIRMADOS EM JUÍZO. PRECEDENTE. TESE DE CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVA INQUISITORIAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (ut, AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014).
2. Não obstante a relutância da defesa, a condenação da agravante resultou não apenas dos elementos produzidos na fase inquisitorial, mas também de prova testemunhal produzida em Juízo, de tal sorte que o Tribunal local não destoou da massiva jurisprudência desta Corte Superior de Justiça cristalizada no sentido de que provas inquisitoriais podem servir de suporte a sentença condenatória, desde que corroboradas sob o crivo do contraditório, como no caso dos autos.
3. Incidência da Súmula 568/STJ: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema." 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 926.253/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 26/08/2016)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Desconstituir o julgamento da Corte a quo, que condenou as agravantes pelo crime de tráfico de drogas, ou aplicar o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, demandaria a incursão na seara fático/probatória, situação inviável ante o óbice contido na Súmula n. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL CONSIDERADO NOTÓRIO. COTEJO ANALÍTICO. IMPRESCINDIBILIDADE. PROVA TESTEMUNHAL. POLICIAIS. VALIDADE.
2. O alegado dissenso pretoriano deve ser demonstrado conforme preconizado nos arts. 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ, mesmo em se tratando de dissídio considerado notório.
3. É entendimento já há muito pacificado neste Sodalício, de que são válidos os testemunhos de policiais, mormente quando não dissociados de outros elementos contidos nos autos aptos a ensejar a condenação.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 482.641/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 08/10/2014)

Os testemunhos dos policiais estão em harmonia com as provas produzidas, especialmente pelos laudos toxicológicos.

Ainda sobre a credibilidade do testemunho dos policiais militares, julgo apropriado rememorar a preleção do Ministro CELSO DE MELLO:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos". (STF - HC - 74.608-0 - de São Paulo - rel. Min. Celso de Mello - DJU 11.04.97, pág. 12.189).

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o fato de o acusado ser surpreendido na posse de drogas, após insuspeita delação anônima, é suficiente para justificar o desfecho condenatório. A propósito, colho os seguintes precedentes do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"EMENTA: Tráfico de entorpecentes. Policiais militares que, após denúncia anônima de que um indivíduo estaria praticando tráfico de entorpecentes, dirigem-se até o local, onde avistam o réu, que trajava as mesmas roupas informadas pela denúncia. Milicianos que permanecem escondidos atrás de uma cerca viva, oportunidade em que visualizam a aproximação de um rapaz em uma motocicleta, que conversa com o acusado e então passa a dar voltas no quarteirão. Réu que se dirige até um banco de areia localizado em um terreno baldio e, ao retornar, entrega droga ao rapaz da motocicleta, que levanta o "eppendorf" contra a luz, permitindo que os policiais constatem se tratar de cocaína. Policiais que decidem realizar a abordagem, momento em que avistam o réu recebendo dinheiro de outro indivíduo, que se encontrava no interior de um veículo e fugiu ao perceber a presença da polícia. Apreensão da quantia de R\$ 11,50 no bolso do acusado, e de 44 porções de cocaína, que se encontravam no referido banco de areia. Palavras dos policiais coerentes e seguras, dando conta da apreensão das drogas. Negativa do acusado isolada. Postura de quem se valia da droga para a mercancia. Condenação de rigor. Desclassificação inviável. Penas bem dosadas. Hipótese que não autorizava mesmo a redução pela aplicação do artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06. Impossibilidade de substituição da pena. Regime fechado adequado (Lei n.º 11.464/07). Apelo improvido. (Relator(a): Pinheiro Franco; Comarca: Araras; Órgão julgador: 7ª Câmara Criminal Extraordinária; Data do julgamento: 12/04/2017; Data de registro: 12/04/2017)".

"EMENTA: Tráfico de Entorpecentes. Policiais militares que, após diversas denúncias anônimas recebidas pela polícia civil e militar dando conta do envolvimento do réu

com o tráfico de entorpecentes, receberam a notícia de que ele estaria embalando e comercializando drogas na praça central da cidade, dirigindo-se até o local. Acusado que, ao perceber a aproximação dos milicianos, foge em direção a uma escola e, na iminência de ser detido, joga duas porções de cocaína em seu interior. Em revista pessoal, os policiais localizam embalagens plásticas vazias e um aparelho celular. Posteriormente, ao entrarem na escola, encontram as porções de cocaína. Os policiais ainda refazem o caminho percorrido pelo réu durante a perseguição, ocasião em que localizam outras duas porções de substância aparentando ser cocaína, além de uma tesoura. Palavras dos agentes públicos coerentes e seguras. Destinação mercantil das drogas bem evidenciada. Prova oral hábil. Condenação pelo tráfico bem decretada. Penas revistas, afastado o aumento da base e aplicado, excepcionalmente, o redutor do §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, em 1/2. Regime fechado absolutamente necessário. Impossibilidade de substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Apelo parcialmente provido. (Relator(a): Pinheiro Franco; Comarca: Monte Alto; Órgão julgador: 7ª Câmara Criminal Extraordinária; Data do julgamento: 12/04/2017; Data de registro: 12/04/2017)"

"EMENTA: Apelação Criminal – TRÁFICO DE ENTORPECENTE. Conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese de absolvição. Depoimentos de policiais. Necessidade de prestigiar o testemunho do agente público, mormente quando não há razão para infirmá-lo. Razoável quantidade de droga e denúncia anônima – Reprimenda. Redução. Afastamento da circunstância judicial desfavorável. Quantidade de droga que não pode ser considerada expressiva – Apelo parcialmente provido. (Relator(a): Rachid Vaz de Almeida; Comarca: São Joaquim da Barra; Órgão julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 23/02/2017; Data de registro: 01/03/2017)."

Percebe-se que o conjunto probatório aponta, de forma suficiente, ter o réu realizado o delito previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06, em suas elementares, na forma descrita na denúncia.

Assim, impossível o reconhecimento do uso de drogas pelo acusado conforme requerido. Destarte, todos esses elementos somados, a quantidade de drogas, o modo de acondicionamento dos entorpecentes, a elevada quantidade de dinheiro, ato da comercialização, deságuam com segurança o propósito de mercancia e de difusão ilícita das drogas, não obstante, enfatizo, o tipo penal do artigo 33 ser congruente.

Assim, não há o que se falar em insuficiência de provas. Destarte, todos esses elementos somados, a quantidade de drogas, o modo de acondicionamento dos entorpecentes, deságuam com segurança o propósito de mercancia e de difusão ilícita das drogas, não obstante, enfatizo, o tipo penal do artigo 33 ser congruente.

Destarte, tendo ficado demonstradas a autoria e a materialidade do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a condenação é de rigor, não havendo o que se falar em insuficiência de provas.

Reconheço, no entanto, que se trata de tráfico privilegiado, na forma do artigo 33, § 4º da Lei n. 11.343/2006, porque o acusado é primário e de bons antecedentes e não há evidências seguras, acima de uma dúvida razoável, de que ele se dedique ao tráfico de drogas ou integre organização criminosa.

Para legitimar a não aplicação do redutor é essencial a fundamentação corroborada em elementos capazes de afastar um dos requisitos legais, sob pena de desrespeito aos princípios da individualização da pena, do estado de não culpabilidade e da fundamentação das decisões judiciais. Desse modo, a habitualidade e o pertencimento a organizações criminosas deverão ser comprovados, não valendo a simples presunção. Não havendo prova nesse sentido, o condenado fará jus à redução de pena. Em outras

palavras, militarará em favor do réu a presunção de que é primário e de bons antecedentes e de que não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa.

O ônus de provar o contrário é do Ministério Público e, na espécie, não há prova judicial idônea, pelo que há boas razões para acreditar que o fato praticado foi isolado na vida do acusado.

Conforme assentado na doutrina: "A habitualidade e o pertencimento a organizações criminosas deverão ser comprovados, não valendo a simples presunção. Não havendo prova nesse sentido, o condenado fará jus à redução de pena". (QUEIROZ, Paulo; LOPES, Marcus. Comentários à Lei de Drogas. 2016. p. 50).

E também: "(...) militarará em favor do réu a presunção de que é primário e de bons antecedentes e de que não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa. O ônus da prova, nesse caso, é do Ministério Público(...)". (GRECO FILHO, Vicente; RASSI, João Daniel. Lei de Drogas anotada. 2009. p. 109).

Nesse sentido, é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: "Habeas corpus. 2. Tráfico de entorpecentes. Condenação. 3. Causa de diminuição de pena do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006. 4. Não aplicação da minorante em razão de sentença sem trânsito em julgado. 5. Paciente primário. 6. Ausência de provas de que integra organização criminosa ou se dedique à prática de crimes. 7. Decisão contrária à jurisprudência desta Corte. Constrangimento ilegal configurado. 7.1. O Pleno do STF, ao julgar o RE 591.054, com repercussão geral, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, firmou orientação no sentido de que a existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado não pode ser considerada como Maus Antecedentes para fins de dosimetria da pena. 7.2. Para efeito de aumento da pena, somente podem ser valoradas como Maus Antecedentes decisões condenatórias irrecorríveis, sendo impossível considerar para tanto investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação ao artigo 5º, inciso LIV (presunção de não culpabilidade), do texto constitucional. 8. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. Superação. 9. Ordem concedida parcialmente para que o Juízo proceda à nova dosimetria" (HC 151.431/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes)

Essa compreensão é a aplicação pura e simples do princípio da dúvida em favor do réu. Conforme magistério do jurista alemão WINFRIED HASSEMER, "O Direito Processual Penal concretizou no princípio 'in dubio pro reo' a consequência mais claramente visível e de maior alcance, em razão das suas dúvidas quanto ao êxito da compreensão cênica. Ele não está formulado expressamente na lei, mas é reconhecido de forma unânime e com razão como um dos princípios fundamentais do nosso Processo Penal. Ele menciona que qualquer dúvida na verdade do caso produzido ou dos seus dados atua em favor do acusado; que este só pode ser condenado quando o Tribunal não tiver nenhuma dúvida sobre a verdade do caso produzido. Disso resulta também que não é o acusado que deve provar a sua inocência, mas o Estado sancionador que deve provar a sua culpa (...) a dúvida jamais pode pesar sobre o acusado. Ele se vê envolvido - em regra contra a sua vontade e sob ameaça de violência - em um discurso institucional, que se baseia nas insuperáveis dificuldades para a obtenção do êxito e da existência bem sucedida da compreensão e da dúvida. O encargo desta dúvida deve ser suportado por aquele que começa o processo, que o conduz, que o leva ao final e arca com as consequências: O Estado sancionador" (Winfried Hassemer. Introdução aos fundamentos do Direito Penal. 2ª edição. Porto Alegre, Sérgio Fabris, 2005, p. 232).

Isso quer dizer que qualquer dúvida deve beneficiar o acusado (TEDH, caso (Barberà, Messegué and Jabardov. Spain, §77), razão pela qual urge reconhecer a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado e aplicar a redução em grau máximo.

Presentes os requisitos legais, é o caso de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Com efeito, no que tange à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ao analisar o HC n. 97.256/RS, o Supremo Tribunal Federal passou a admitir tal possibilidade, nos termos do art. 44, do Código Penal, reconhecendo a inconstitucionalidade da parte final do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, que posteriormente teve sua execução suspensa pelo Senado Federal, por meio da Resolução n. 05/2012. Logo, não há base legal para tolher o direito à substituição da pena privativa por restritiva e a singela opinião do julgador sobre a gravidade abstrata do delito não é motivo idôneo para decidir em contradição com a Resolução n. 05/2012 do Senado Federal.

Assentado o tráfico de drogas, todas as evidências demonstram que o dinheiro apreendido é proveito do tráfico, pelo que deve ser decretado seu perdimento. Quando a Defesa tomou conhecimento do auto de exibição e apreensão, poderia ter demonstrado a origem lícita do numerário, até sentença final, o que não ocorreu. O perdimento do dinheiro é corolário lógico, na forma determinada pelo artigo 63, § 1º, da Lei Federal 11.343/06, e até mesmo em função do art. 92, II, letra a e b, do Código Penal. Não há provas seguras da origem lícita do dinheiro, o que autoriza, a princípio, a conclusão de que o dinheiro é produto do crime de tráfico, não desincumbindo-se o acusado do ônus que lhe competia de provar o contrário.

III - DISPOSITIVO

Por todos esses fundamentos, condeno LUCIANO DA SILVA LOPES sanções do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena (artigo 5º, inciso XLVI, Constituição Federal), passo a dosar a sanção penal do acusado, observado o sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal.

Ausentes circunstâncias judiciais negativas (artigo 59 do Código Penal), fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Ausentes agravantes e atenuantes.

Estão satisfeitos os requisitos do § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, como já fundamentado.

Fica o réu definitivamente condenado à pena de 01 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal.

Fixo o regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, tendo em vista que a gravidade abstrata do delito não é suficiente para autorizar a aplicação de regime mais gravoso, consoante súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal. Essa disposição, aliás, resulta da aplicação da ordem de habeas corpus expedida pelo Superior Tribunal de Justiça no HC n. 593.603.

Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal e dosada pena superior a 1 (um) ano, substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, na forma do artigo 44, § 2º do Código Penal.

Portanto, em observância aos artigos 44, § 2º e 46 do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade aplicada por duas restritivas de direitos, consistente em limitação de fim de semana e prestação pecuniária, consistente no pagamento de 02(dois) salários-mínimos em favor de entidade credenciada perante o juízo. As

condições da limitação de fim de semana serão aclaradas na fase de execução.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, por não vislumbrar motivos que justifiquem a segregação cautelar (prisão preventiva) ou estabelecimento de medida cautelar diversa de prisão. Fixada pena a ser cumprida em regime aberto e com substituição por restritiva de direitos, a prisão preventiva afigura-se excessiva e desproporcional.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais. Eventual causa de isenção deverá ser avaliada pelo Juízo da Execução Penal.

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

Não havendo impugnação ao laudo pericial, inexistindo assim dúvida sobre a natureza da droga e considerando as precárias condições de acondicionamento destas substâncias na Delegacia de Polícia, determino que, caso ainda não tenha sido feito, oficie-se, independentemente do trânsito em julgado, comunicando a autorização para incineração dos entorpecentes apreendidos.

Determino, outrossim, o perdimento em favor da União do dinheiro depositado à disposição desse juízo, nos termos da Lei nº 11.343/06, a ser comunicado após o trânsito em julgado.

Após o trânsito em julgado desta sentença, tomem-se as seguintes providências:

- a) Calcule-se o valor da multa fixada na sentença, intimando-se o réu para o pagamento em 10 (dez) dias (art. 50 do CP). Transcorrido o referido prazo *in albis*, a multa será considerada dívida de valor, aplicando-se as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, nos termos do artigo 51 do Código Penal, devendo a eventual ausência de pagamento ser informada à Fazenda Pública, mediante cópia integral deste processo.
- b) Expeça-se Guia de Execução Penal de acordo com o disposto nos artigos 105 e 106 da Lei de Execuções Penais, remetendo uma cópia ao Juízo da Vara das Execuções Penais competente, outra ao diretor do estabelecimento prisional onde o réu deve cumprir a pena e outra ao Conselho Penitenciário.
- c) Em obediência ao § 2º do art. 71 do Código Eleitoral, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo para cumprimento do art. 15, III, da Constituição Federal, com cópia desta sentença e com o registro de que a suspensão dos direitos políticos deve ser mantida enquanto não declarada a extinção da sanção penal.

P.I.C.

São Joaquim da Barra, 07 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA